

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 21/08/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC 015813.989.24-1.

Representante: Verocheque Refeições Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia.

Responsável: Miguel José Araujo Junior - Prefeito.

Assunto: Representação em face do edital da Chamada Pública de Credenciamento Eletrônico nº 001/2024, processo administrativo nº 012/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores públicos do Município de Nova Luzitânia (SP), com taxa de administração a custo zero.

Valor estimado: R\$ 1.174.117,50 (um milhão cento e setenta e quatro mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos).

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.

Advogados habilitados no e-tcesp: Paulo André Simões Poch (OAB/SP nº 181.402); Diego Alves de Oliveira (OAB/SP nº 349.932).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CHAMAMENTO PÚBLICO. CREDENCIAMENTO. ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE ÚNICA EMPRESA COM MAIOR NÚMERO DE VOTOS DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS. IRREGULAR. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO PROCEDIMENTO AUXILIAR PREVISTO NO ARTIGO 79 DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA.

1. O credenciamento promovido com base no inciso II do artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 não permite que o certame licitatório contenha critério de seleção que resulte na contratação de apenas uma das proponentes habilitadas, pois referida regra configura desvirtuamento da finalidade essencial do credenciamento, que consiste na seleção de todos os ofertantes que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço, preservada a possibilidade de seleção do contratado pelo beneficiário direto da prestação e o credenciamento permanente de novos interessados.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** em face do edital da Chamada Pública de Credenciamento Eletrônico nº 001/2024, processo administrativo nº 012/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA**, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores públicos do Município de Nova Luzitânia (SP), com taxa de administração a custo zero.

1.2. A Representante contesta o critério de escolha da empresa contratada¹, que faz com que o credenciamento resulte na contratação de

¹ **9.6. DA ELEIÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA**

9.6.1. Em caso de mais de uma habilitada, as empresas habilitadas serão convocadas para em um prazo de até 02 (dois) dias úteis, disponibilizar um link de acesso ao seu portal/site onde constará seu material de divulgação do produto/serviço para livre acesso a todos os empregados beneficiários para consulta e pesquisa, com a possibilidade de prorrogação e/ou alteração de acordo com a necessidade da Prefeitura.

9.6.2. Também será permitido a utilização de material de divulgação impresso, cabendo a empresa habilitada a obrigação de fornecimento junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura.

9.7. A campanha de publicidade será realizada, por meio de comunicados aos seus empregados, disponibilizando os endereços eletrônicos para acesso e análise dos produtos.

9.8. As empresas também serão comunicadas do início da campanha visando à transparência e isonomia desta etapa. Por força do Art. 175-A do Decreto nº 10.854/2021, e o inciso III do art. 3º da Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022, são vedados quaisquer “programas de recompensa que envolvam operações de cashback”. Quando da apresentação do material de marketing, não será permitido a ofertar valor extra (bônus de boas-vindas ou outros benefícios diretos).

9.9. O prazo para conhecimento do material de cada uma das empresas habilitadas será no mínimo de 05 (cinco) dias, consecutivos a todas as participantes, a partir do encerramento do prazo de envio.

9.10. Encerrado o prazo do conhecimento pelo beneficiário dos materiais de divulgação apresentados, iniciar-se a votação.

9.11. A seleção para a escolha do primeiro classificado ocorrerá, dentre as empresas credenciadas habilitadas, por meio da votação não obrigatória entre os beneficiários, de acordo com o art. 14 da Constituição Federal, seguindo os seguintes critérios:

apenas uma empresa, que será a que conquistar maioria de votos dos servidores, em possível desvirtuamento do credenciamento disciplinado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Ao analisar inicialmente a impugnação do Autor, observei que as regras de seleção do ato convocatório denotaram, a princípio, um procedimento de credenciamento que resultaria na seleção de apenas uma empresa, em possível desvirtuamento das finalidades do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, razão pela qual a matéria foi submetida ao E. Tribunal Pleno na sessão de 24/07/2024, ocasião em que foi deferida, com fundamento no artigo 171, §1º da Lei 14.133/21 e nos artigos 220 e seguintes do Regimento Interno, a **SUSPENSÃO CAUTELAR** do procedimento impugnado, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias úteis** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA** prestar informações, esclarecimentos e encaminhar os documentos cabíveis face ao ponto impugnado que fundamentou a ordem de suspensão do certame, requisitados nos termos do artigo 171, § 2º da Lei nº 14.133/21, juntamente com os demais

9.11.1. O Sistema de seleção (votação) será através de urna disponibilizada no Departamento de Pessoal, em dia e horários estipulados, com cédula identificando o nome das empresas habilitadas, para votação. A definição da ordem das empresas credenciadas habilitadas na cédula será pela ordem alfabética.

9.11.2. A Votação as condições para livre manifestação do empregado beneficiário (eleitor) por meio das seguintes opções: voto nas empresas credenciadas habilitadas.

9.11.3. O Voto será secreto e universal, não sendo permitindo a identificação do voto.

9.11.4. Cada servidor beneficiário poderá votar apenas uma vez, vinculando ao numero de sua matrícula, receberá a cédula de votação.

9.11.5. A empresa vencedora será aquela que obtiver o maior número de votos dentre as participantes.

9.11.6. O resultado da votação será comunicado, através de publicação no Diário Oficial do Município.

9.11.7. Os empregados beneficiários que não participarem da seleção nos prazos indicados obrigatoriamente integrará a listagem de empregados da empresa escolhida como vencedora da cotação.

elementos relacionados com o certame em questão, o que incluiu cópia integral do Edital e dos seus anexos.

1.5. Notificada, a Prefeitura esclareceu que o seu Setor de Licitação cumpriu a determinação de suspensão do procedimento licitatório, mas que, em seguida, retificou o edital sanando as irregularidades apontadas e o republicou com a designação de nova sessão pública para o dia 21/08/2024 às 10h00min.

Requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do objeto (evento 32).

1.6. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 40) emitiu parecer no sentido da **procedência** da representação, propondo a aplicação de multa com fundamento no artigo 104, inciso III da Lei Complementar Estadual nº 709/93, pois *“embora tenha constado expressamente da decisão liminar determinação para a Comissão de Licitação “abster-se da realização ou prosseguimento de qualquer ato a ele relacionado até a ulterior deliberação por esta Corte, ressalvada a hipótese de revogação ou anulação nos termos do artigo 71 da Lei 14.133/21”, a informação da Administração Municipal é de que foi dado seguimento ao certame com a retificação e republicação do edital, em patente desrespeito à determinação exarada por esse egrégio TCESP, o que impõe a aplicação de multa aos responsáveis”*.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 16/08/2024
TC-015813/989/24-1

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** em face do edital da Chamada Pública de Credenciamento Eletrônico nº 001/2024, processo administrativo nº 012/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA**, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros alimentícios para os servidores públicos do Município de Nova Luzitânia (SP), com taxa de administração a custo zero.

2.2. Considero procedente a crítica incidente sobre o critério de escolha da empresa contratada, na mesma linha de entendimento contida no parecer do D. Ministério Público de Contas.

Não é possível permitir que um procedimento de credenciamento fundado no artigo 79 da Lei Federal nº 14.133/21 tenha prosseguimento com um critério de seleção como o definido na cláusula 9.6², que cria uma fase

² **9.6. DA ELEIÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA**

9.6.1. Em caso de mais de uma habilitada, as empresas habilitadas serão convocadas para em um prazo de até 02 (dois) dias úteis, disponibilizar um link de acesso ao seu portal/site onde constará seu material de divulgação do produto/serviço para livre acesso a todos os empregados beneficiários para consulta e pesquisa, com a possibilidade de prorrogação e/ou alteração de acordo com a necessidade da Prefeitura.

9.6.2. Também será permitido a utilização de material de divulgação impresso, cabendo a empresa habilitada a obrigação de fornecimento junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura.

9.7. A campanha de publicidade será realizada, por meio de comunicados aos seus empregados, disponibilizando os endereços eletrônicos para acesso e análise dos produtos.

incidental definida como “Campanha de Publicidade” e submete as empresas habilitadas a uma votação não obrigatória entre os servidores visando a contratação apenas da empresa eleita pela maioria dos beneficiários.

A hipótese do inciso II do artigo 79 da Lei 14.133/21, que permite o uso do credenciamento para os casos em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação não autoriza a estruturação de certame cujo resultado consiste em contratar apenas uma das habilitadas, pois inviabiliza inclusive o atendimento ao que dispõe o inciso I do Parágrafo único do artigo 79, que determina que a Administração permita o cadastramento permanente de novos interessados.

9.8. As empresas também serão comunicadas do início da campanha visando à transparência e isonomia desta etapa. Por força do Art. 175-A do Decreto nº 10.854/2021, e o inciso III do art. 3º da Lei nº 14.442, de 2 de setembro de 2022, são vedados quaisquer “programas de recompensa que envolvam operações de cashback”. Quando da apresentação do material de marketing, não será permitido a ofertar valor extra (bônus de boas-vindas ou outros benefícios diretos).

9.9. O prazo para conhecimento do material de cada uma das empresas habilitadas será no mínimo de 05 (cinco) dias, consecutivos a todas as participantes, a partir do encerramento do prazo de envio.

9.10. Encerrado o prazo do conhecimento pelo beneficiário dos materiais de divulgação apresentados, iniciar-se a votação.

9.11. A seleção para a escolha do primeiro classificado ocorrerá, dentre as empresas credenciadas habilitadas, por meio da votação não obrigatória entre os beneficiários, de acordo com o art. 14 da Constituição Federal, seguindo os seguintes critérios:

9.11.1. O Sistema de seleção (votação) será através de urna disponibilizada no Departamento de Pessoal, em dia e horários estipulados, com cédula identificando o nome das empresas habilitadas, para votação. A definição da ordem das empresas credenciadas habilitadas na cédula será pela ordem alfabética.

9.11.2. A Votação as condições para livre manifestação do empregado beneficiário (eleitor) por meio das seguintes opções: voto nas empresas credenciadas habilitadas.

9.11.3. O Voto será secreto e universal, não sendo permitindo a identificação do voto.

9.11.4. Cada servidor beneficiário poderá votar apenas uma vez, vinculando ao número de sua matrícula, receberá a cédula de votação.

9.11.5. A empresa vencedora será aquela que obtiver o maior número de votos dentre as participantes.

9.11.6. O resultado da votação será comunicado, através de publicação no Diário Oficial do Município.

9.11.7. Os empregados beneficiários que não participarem da seleção nos prazos indicados obrigatoriamente integrará a listagem de empregados da empresa escolhida como vencedora da cotação.

A contratação de um único credenciado não contemplaria o interesse da totalidade dos servidores, mas apenas o da maioria, reduzindo a comodidade e satisfação dos demais.

As regras de seleção do ato convocatório denotam um credenciamento que resultará na seleção de apenas uma empresa, configurando desvirtuamento da finalidade essencial do procedimento auxiliar disciplinado no artigo 79 da Lei 14.133/21, que consiste na seleção de todos os particulares que preencham os requisitos necessários para o fornecimento de determinado bem ou serviço.

Vale registrar que o artigo 6º, XLIII, da Lei nº 14.133/21 define o credenciamento como *“processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados”*.

A prevalência desta estratégia de contratação elaborada pela Municipalidade tornaria inócuo o disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 79 da Lei 14.133/21, que determina à Administração a manutenção de *“edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”*, na medida em que, uma vez assinado o contrato, eventuais novas empresas credenciadas não teriam possibilidade de contratar com a Administração.

A questão não é inédita neste E. Tribunal e a solução proposta no presente voto adota a linha de entendimento tomada no julgamento dos TCs 011912.989.24-1 (Tribunal Pleno – Sessão de 19/06/2024) e 11440.989.24-2 (Tribunal Pleno, Sessão de 19 de junho de 2024 – Acórdão publicado no DOE de 27/06/2024), ambos de minha Relatoria, entre outros.

2.3. O voto aprovado por este E. Tribunal Pleno na sessão de 24/07/2024 e que propôs a suspensão cautelar do certame licitatório expressamente determinou que a Comissão de Licitação se abstinisse da realização ou prosseguimento de qualquer ato relacionado ao procedimento até a ulterior deliberação por esta Corte, ressalvada a hipótese de revogação ou anulação nos termos do artigo 71 da Lei 14.133/21.

De acordo com as informações prestadas pela própria Prefeitura no evento 32, a Administração inicialmente cumpriu a determinação de suspensão do procedimento licitatório. Porém, em seguida, tratou de retificar e republicar o edital com as correções que entendeu pertinentes, além de designar nova data para a sessão pública para a data de hoje, 21/08/2024.

Independente da natureza e da correção das retificações feitas, cujo juízo de mérito não cabe neste processado, a continuidade do certame licitatório, em tese, expôs a autoridade responsável pelo certame às sanções do artigo 104, §1º da Lei Complementar nº 709/93³.

No entanto, deixo de propor a aplicação de multa no presente caso por ter a Municipalidade informado a esta Corte no evento 32 as providências corretivas que adotou no exercício da autotutela administrativa, além de não ter sido demonstrada a produção de efeitos das regras impugnadas na representação e que motivaram a ordem de suspensão cautelar deliberada pelo Tribunal Pleno em 24/07/2024.

³ **Artigo 104** - O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por:

[...]

§ 1º - Ficará sujeito à multa prevista neste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal de Contas, salvo motivo justificado.

Todavia, **RECOMENDO** a observância dos procedimentos previstos no artigo 71 da Lei 14.133/21 em outras situações semelhantes.

2.4. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação para o efeito de confirmar no edital examinado o desatendimento às regras do procedimento de credenciamento previstas no artigo 79 da lei Federal nº 14.133/21 e a **irregularidade** das cláusulas impugnadas que determinam a contratação de apenas uma proponente após submeter as empresas habilitadas a um processo de votação entre os servidores beneficiários.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro